

1509182-39.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... pela forma consumada do crime de tráfico de drogas.

Outrossim, a intenção do tráfico ilícito de drogas restou indubitável em razão da quantidade da droga apreendida, forma de acondicionamento e comportamento do acusado antes da apreensão. Além disso, improvável que o réu, que não tem sequer emprego fixo, adquirisse tamanha quantidade de entorpecentes para consumo próprio. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509182-39.2021.8.26.0344 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509182-39.2021.8.26.0344

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2259793/2021 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO, 20424656 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO,

7336/21/504 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO, 2259793 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 7336/21/504

- DISE- DEL.SEC.MARÍLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELTON ELIAS DA SILVA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Vistos.

WELTON ELIAS DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 03hs46min, na Rua Kintaro Mitsuka, 1685, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 11,88 (massa líquida) de Cannabis Sativa L (Maconha) divididas em 04 (quatro) porções, 25,91 (massa líquida) de cocaína, armazenadas em onze microtubos e 13,55 (massa líquida) de crack, armazenadas em onze microtubos, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 95/97), o réu foi citado (fls. 1382) e apresentou resposta à acusação (fls. 1385/1393).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo, o acusado, interrogado ao final (fls. 1429/1430).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido nos termos da denúncia. Pugnou pela fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal em razão da natureza das drogas e o reconhecimento da agravante da reincidência na fase intermediária, sem atenuantes. Requereu o afastamento da causa de diminuição por tráfico privilegiado. Pleiteou a fixação do regime inicial fechado por se tratar de crime equiparado a hediondo e em razão da recidiva do réu. Entendeu inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e presentes os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar. Pugnou pela decretação da perda do aparelho celular (instrumento do crime) e do dinheiro (produto do crime) apreendidos com o acusado (fls. 1438/1444).

O Defensor, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pediu a fixação de regime mais brando para cumprimento de eventual pena a ser aplicada em caso de condenação (fls. 1448/1458).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 27/29), laudo de constatação (fls. 23/25), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/82) e pela prova oral colhida. Os policiais militares Marcelo Gonçalves Claro e Paulo Sérgio Queiroz, na fase inquisitiva, relataram que, durante patrulhamento preventivo no distrito de Padre Nóbrega, avitaram o acusado Welton Elias da Silva Alves caminhando pela Rua José Antônio de Paula, por volta das 22h40, o qual, ao ver a viatura policial, demonstrou certo nervosismo e mudou o sentido de direção, passando a caminhar de forma mais célere. Narraram que, diante disso, o réu foi abordado e, durante vistoria pessoal, localizaram no bolso da jaqueta do acusado uma sacola plástica, abrigando em seu interior quatro invólucros contendo erva esverdeada semelhante a maconha, onze microtubos plásticos contendo pó amarelado semelhante ao crack e onze microtubos plásticos contendo pó branco semelhante a cocaína, além de R\$72,00 em dinheiro e um telefone celular da marca Motorola, cor branca. Afirmaram que, em razão desses fatos, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado à presença da autoridade policial (fls. 5/6). Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram a narrativa anterior. Afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina e, no momento em que adentraram a via, o réu os avistou e adotou atitude suspeita, mudando de direção e de comportamento. Abordado e realizada busca pessoal, encontraram com ele, no bolso da blusa, um invólucro (uma sacolinha) contendo cocaína, crack e maconha. No bolso da bermuda, R\$72,00. Indagado, afirmou que o acusado disse que pegou as drogas com um rapaz no bairro Maracá para fazer a venda no local da abordagem. Os depoentes não conheciam o réu. Esclareceram que não havia outra pessoa com o acusado naquela ocasião, bem como que foi abordado próximo a um bar, na calçada.

O réu, por sua vez, afirmou, em sede administrativa, ser usuário de drogas e trabalhar na "Serralheria do Gringo", situada em Padre Nóbrega. Alegou que, no dia dos fatos, recebeu R\$300,00 e foi até Marília para comprar droga para seu próprio uso. Relatou que, no momento em que estava voltando, foi abordado pela guarnição policial, já no distrito de Padre Nóbrega, sendo localizados os entorpecentes anteriormente adquiridos, ou seja, onze microtubos com crack, onze microtubos com cocaína e, ainda, porções de maconha, além dos R\$72,00 reais e um aparelho celular. Informou que, a cada dez "pinos" comprados, ganhava um, por isso onze pinos de cada droga. Sustentou não ser traficante, apenas usuário. Pontuou possuir uma passagem antiga por delito contra patrimônio (fls. 7). Na fase judicial, afirmou que trabalhava em uma serralheria localizada no bairro Maracá. Explicou que foi preso por volta das 21 horas, em Padre Nóbrega. Disse que tinha R\$300,00 e que adquiriu dez porções de cocaína e dez porções de crack. Esclareceu que, a cada compra de dez

porções, ganhava uma, sobejando-lhe, assim, R\$70,00. Afirmou que estava acompanhado de um rapaz, com quem parou defronte a um bar, momento em que foi abordado pela guarnição policial. Afirmou ser usuário diário de drogas (crack, maconha e cocaína) desde os 15 anos de idade, tendo, hoje, 25. Disse que o uso era diário e assim foi por 10 anos. Não obstante, nunca foi internado e, desde que preso, não fez uso de mais nenhuma substância ilícita, mesmo sem tratamento para tanto. Pontuou não se recordar do número de seu telefone celular.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo réu.

Por primeiro, de se ressaltar que não há motivos para desmerecer os depoimentos dos policiais, sobretudo porque o réu não demonstrou que as testemunhas quisessem prejudicá-lo gratuita e deliberadamente. Vale dizer que inexistem nos autos dados concretos no sentido de que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob compromisso, quisessem mentir.

O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.4.2020).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, repetindo-se na judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu. Inegável que a droga foi apreendida com o acusado, que confirmou em juízo trazê-las consigo, amoldando-se a conduta à figura típica de trazer consigo descrita no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. De fato, o acusado conduzia pessoalmente a droga, para venda a terceiras pessoas.

Diante desse cenário, não há se cogitar em insuficiência probatória (in dubio pro reo), atipicidade da conduta ou crime tentado, tampouco em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

A imputação que consta da denúncia é no sentido de que o acusado trazia consigo drogas que determinam dependência química e física sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, núcleo contido no tipo incriminador do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, delito de caráter permanente, cuja consumação ocorre no momento em que o agente realiza a conduta típica, prolongando-se no tempo durante o período em que o réu estava com a droga, autorizando, inclusive, a prisão em flagrante delito, como ocorreu no caso versado. Portanto, evidente que, se o sujeito ativo é preso trazendo consigo droga, responde pela forma consumada do crime de tráfico de drogas.

Outrossim, a intenção do tráfico ilícito de drogas restou indubitável em razão da quantidade da droga apreendida, forma de acondicionamento e comportamento do acusado antes da apreensão. Além disso, improvável que o réu, que não tem sequer emprego fixo, adquirisse tamanha quantidade de entorpecentes para consumo próprio. Urge anotar que a jurisprudência é no sentido de que "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Destaca-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de que "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp n.º 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6.T., j. 10.6.2014).

Além disso, a conclusão da traficância praticada pelo acusado ressoa nos diálogos extraídos a partir do aparelho celular apreendido em poder do réu. Conforme destacado pelo Ministério Público (fls. 1442), a pessoa identificada como Laura questiona o acusado se "Tá tendo maconha pra comprar aí?" (fls. 957), ao que o acusado responde afirmativamente, inclusive afirmando que levaria a droga até a adquirente, que insiste com o réu "Se tem a poha da maconha pra vende?" (fls. 967), sobreindo nova fala do acusado no sentido de que lhe daria um "baseado" para ela

fumar, conforme se extrai dos áudios extraídos da perícia no aparelho celular apreendido, denotando a prática da mercancia ilegal pelo acusado.

Diante de tais fatos e circunstâncias, forçoso concluir que o acusado praticou, de fato, a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Com base no que está ali descrito é possível identificar em qual condição se encaixa o acusado. Nesse contexto, observa-se que a variedade e a quantidade de entorpecentes apreendida (4,35g - massa líquida - de Cannabis sativa L, dividida em 4 (quatro) invólucros plásticos; 1,13g - massa líquida - de cocaína, dividida em 11 (onze) microtubos plásticos do tipo "eppendorf"; e 1,36g - massa líquida - de cocaína, dividida em 11 (onze) microtubos plásticos do tipo "eppendorf"), o alto poder vulnerante deles, além da forma de embalo, revelam a traficância praticada pelo acusado.

Assim, considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantidade de entorpecentes apreendida; natureza altamente vulnerante das drogas; acondicionamento típico para venda; quantia em dinheiro apreendida sem comprovação de origem lícita; circunstâncias em que flagrado); prova pericial no celular, forçoso concluir, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06, que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando, pois, de mero usuário.

Ressalte-se, a propósito, que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico de drogas, a Lei n.º 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, considerando o disposto nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, assim como dos artigos 42 e 43, ambos da Lei n.º 11.343/2006, observa-se que a quantidade de droga apreendida com o réu, além do alto poder vulnerante, autoriza a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de periculosidade do agente e de reprovabilidade da conduta. Assim, estabeleço a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência em razão de anterior condenação transitada em julgado (Processo nº 0016628-46.2016.8.26.0344, desta E. 1.ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 28/01/2019 - fls. 35/36), razão pela qual exaspero a pena em mais 1/6 (um sexto), resultado em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na derradeira fase, sem causas de aumento de pena. Inviável a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da reincidência do acusado, fixando-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios para fixação da pena privativa de liberdade, é imposta em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada qual no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado,

ex vi do artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, considerando a reincidência do réu.

Pelas mesmas razões e, ainda, pelo quantum de pena imposta, restam ausentes os requisitos objetivos e subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, de modo que se afigura incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena.

A teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário. Ainda, tendo em vista a fixação do regime se deu pela reincidência, resta afastada a imediata aplicação do dispositivo em comento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar WELTON ELIAS DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, inclusive a reincidência, nega-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, ainda mais porque permaneceu preso durante todo o processo para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação, sendo imprescindível evitar-se reiteração delitiva.

Declaro o perdimento, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, do valor apreendido (R\$72,00 - setenta e dois reais), conforme auto de exibição/apreensão (fls. 11), por ausência da comprovação da origem lícita do dinheiro, bem como do aparelho celular (fls. 11) utilizado na prática do comércio espúrio, como consequência da condenação. Oficie-se, oportunamente.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente para efetuar o recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando suspensa a exigibilidade caso seja beneficiário da gratuidade da justiça.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial para que providencie a destruição da droga apreendida, contraprovas e eventuais embalagens, apetrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos termos do artigo 72 da Lei n.º 11.343/06, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C.

Marília, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA